

《[문제1] A공사는 고속국도의 설치·관리 및 통행료 수납업무를 수행하는 공기업이다. 개인사업자 B는 2018. 6. 30. A공사에서 정년퇴직한 자로서, 2018. 12. 31. 수의(隨意)계약 방식으로 A공사와 통행료 수납업무에 관한 용역계약을 체결하였다(계약기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.). B는 용역업체의 창업에 소요된 5천만 원 전액을 A공사로부터 연 1%의 이자율로 차입하여 조달하였고, 별도의 사무실을 두지 않았으며, 용역계약에 따라 A공사의 영업소에서 근무할 수납원 외에는 다른 근로자를 채용하지 않았으며, 2020. 8. 15.까지 A공사 이외의 거래처에서 발생한 매출은 없다. B는 용역계약의 이행을 위하여 2019. 1. 1. A공사로부터 소개받은 甲과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였다. 甲은 채용과 동시에 A공사가 관리하는 ○○영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 계속 근무하고 있다.

한편, C사는 시설관리 등을 사업목적으로 2000. 1. 1. 설립된 회사로서 2020. 8. 15. 현재 자본금은 5억 원이며, 다수의 거래처로부터 시설관리 등의 업무를 도급받아 수행하고 있다. 다만, C사는 근로자파견사업의 허가를 받지 아니하였다. C사는 2017. 12. 31. 공개입찰 방식으로 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.의 1년의 계약기간으로 A공사와 통행료 수납업무 용역계약을 체결하였고, 이후 같은 방식으로 두 차례 계약을 갱신하였다. C사는 기존에 근무하던 수납원이 퇴직하여 결원이 생기자 구직자를 모집하여 2019. 8. 14. 乙과 1년의 계약기간으로 근로계약을 체결하였다. 乙은 채용과 동시에 A공사가 관리하는 △△영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 근무하던 중 2020. 8. 13. 계약기간이 만료되어 C사에서 퇴사하였다. C사는 乙에게 기존과 동일한 조건으로 근로계약을 갱신할 것을 제안하였으나, 乙은 A공사에게 나를 직접 고용하라고 요구하였다. 乙이 그 제안을 거절하였다.

A공사는 사전에 정해 둔 용역대금 산정기준에 따라 B 및 C사 등 외주업체와 용역계약을 체결하였고, A공사의 영업소는 A공사의 직원인 소장, 과장, 대리, 주임과 외주업체 소속인 수납원으로 구성되어 있다. 수납원들은 A공사의 영업소 사무실로 출근하여 A공사의 로고가 새겨진 근무복과 명찰을 착용한 후 주임으로부터 지시사항을 전달받고 요금소로 이동하여 통행료 수납업무 등을 수행하였다. 또 수납원들은 교대시간 또는 근무시간 종료 후 사무실로 이동하여, 징수한 통행료를 확인한 후 주임에게 입금확인서와 개인별 근무확인서를 작성·제출하였고, 주임은 이러한 개인별 근무확인서의 내용이 A공사의 전산시스템에 자동 저장된 정보와 일치하는지 확인하고 소장의 결재를 받았다. 한편, 외주업체들은 영업소 소장에게 매월 소속 수납원들의 근무편성표, 출퇴근 사항을 보고하였다. A공사는 2018. 1. 1. 통행료 수납업무와 관련하여 고객을 응대할 때의 행동, 표정, 언어, 예절, 자세, 예외적 상황별 고객 응대 요령 등이 기재된 매뉴얼을 제작하여 외주업체에 배포하였고, 외주업체 소속 수납원들은 이러한 매뉴얼에 따라 업무를 수행하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 乙은 자신이 A공사에 파견된 근로자였음을 이유로 A공사가 자신을 직접 고용할 의무가 있다고 주장한다. 판례법리에 근거하여 乙의 주장의 타당성을 논하시오. (다만, 파견대상업무에 관한 부분은 논점에서 제외한다.) (30점)》

<문제1의 물음2> 통행료 수납원의 근로자파견 여부 및 무허가 파견에 따른 직접고용의무

I. 문제의 제기

- 사안은 A공사가 통행료 수납업무를 외주업체와 용역계약 형식으로 수행하는 과정에서, 외주업체 C사와 근로계약을 체결하고 실제 A공사의 영업소에서 근무한 乙이 자신은 실질적으로 A공사에 파견된 근로자에 해당하며, 따라서 A공사가 파견근로자보호 등에 관한 법률(이하 '파견법') 제6조의2에 따른 직접고용의무를 부담한다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 통행료수납원 乙과 A공사의 관계가 근로자파견에 해당하는지, 근로자파견에 해당한다면 무허가 파견업체인 C사에서 乙이 1년만 근무했음에도 A공사에게 직접고용의무가 발생하는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 근로자파견과 도급의 구별 및 무허가 파견에 따른 직접고용의무 법리를 살펴보고 사안에 적용하여 乙 주장의 타당성을 논한다.

II. 근로자파견의 판단 기준 및 직접고용의무 법리

1. 근로자파견과 도급의 구별 기준

(1) 구별 원칙

- 근로자파견 여부는 용역계약과 같은 형식적 계약의 명칭과 무관하게 실질적인 사용 형태에 따라 판단한다.

(2) 대법원의 구체적 판단 기준

- 대법원은 원청이 하청 근로자에게 업무상 지휘·명령을 하는지, 하청 근로자가 원청 소속 근로자와 공동근로체를 구성하여 편입되었는지, 하청업체가 채용·배치 등 독자적 인사관리권을 행사하는지, 하청업체가 전문성과 인프라를 갖춘 독립된 기업인지, 수행 업무가 구별되는 독립적 성격인지 등을 종합 고려하여 판단한다.

2. 불법파견에 따른 직접고용의무 발생 법리

(1) 무허가 파견의 즉시 발생

- 파견법 제6조의2 제1항 제5호에 따라 사용사업주가 허가받지 않은 자로부터 파견 역무를 제공받은 무허가 파견의 경우 직접고용의무가 발생한다. 무허가 파견은 적법 파견과 달리 사용 기간이 2년을 초과했는지 여부와 무관하게 즉시 직접고용의무가 발생한다.

(2) 계약 만료 시 직접고용권의 유지

- 직접고용의무는 강행규정이므로, 파견계약기간이 만료되었거나 근로자가 하청의 계약 갱신을 거절하였다 하더라도 이미 발생한 사용사업주의 직접고용의무와 근로자의 직접고용청구권은 소멸하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 乙의 근로자파견 해당 여부

(1) 지휘·명령 및 공동근로체 편입성

- 수납원들은 A공사의 근무복을 입고 A공사 주임으로부터 직접 업무 지시를 받았으며, 퇴근 시 징수 통행료를 보고하고 전산 확인을 거쳤다. 업무 수행도 A공사의 매뉴얼에 구속되었다. 이는 A공사가 구체적인 지휘·명령을 행사하여 乙이 A공사의 공동근로체에 실질적으로 편입되었음을 보여준다.

(2) 인사관리 및 독자성 결여

- C사가 독립 법인격을 갖추었더라도 근무편성과 출퇴근을 매월 A공사에 보고해 통제를 받았다. 또한 수납업무는 특별한 기술이 필요 없는 표준화된 업무로서 A공사 사업의 필수적 일부이다. 따라서 C사는 인사관리 및 독자성을 결여하였으므로 乙의 근로 실질은 근로자파견에 해당한다.

2. A공사의 직접고용의무 성립 여부

(1) 무허가 파견과 직접고용의무

- C사는 무허가 파견업체이므로 파견법을 위반한 무허가 파견에 해당한다. 무허가 파견은 즉시 직접고용의무가 발생하므로, 乙의 파견근로기간이 1년에 불과하여 2년을 초과하지 않았더라도 A공사는 乙을 직접 고용할 의무를 진다.

(2) 갱신 거절과 고용의무 유지

- 乙이 C사의 계약 갱신 제안을 거절하고 A공사에 직접고용을 요구한 것은 적법한 권리 행사이다. 하청과의 계약 종료로 사용사업주의 고용의무가 소멸하지 않으며, 乙이 직접고용에 반대하지 않고 적극적으로 청구하므로 A공사는 乙을 직접 고용하여야 한다.

IV. 결론

- 乙의 근로관계 실질은 근로자파견에 해당하며, C사는 무허가 파견업체이다. 무허가 파견은 파견 기간이 2년 미만이라도 사용사업주에게 즉시 직접고용의무가 발생한다. 乙이 C사의 근로계약 갱신을 거절했더라도 이미 발생한 직접고용의무는 소멸하지 않는다. 따라서 자신을 직접 고용하여야 한다는 乙의 주장은 정당하다.